

1501613-95.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-

3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501613-95.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285848/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 20918439 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 116/21/592 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2285848 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE CONTIERI NOBRE

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Tramitação prioritária

Aos 25 dias do mês de agosto de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MM. Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o Dr. Rodrigo Correa Godoy, defensor do réu. Apresentados o acusado ALEXANDRE CONTIERI NOBRE, as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira e Leonardo Cavalcanti de Oliveira, e as testemunhas arroladas pela defesa: Jean Lucas Gonçalves Peniche e Júlio César Bonifácio.

Ausente a testemunha da defesa Anderson de Souza Silva, não localizado pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de fls.321.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do acusado com seu defensor, em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao acusado a observação determinada no artigo 186

do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns (Marcelo e Leonardo), da defesa (Jean e Júlio), pelo sistema virtual.

Pelo defensor foi dito que desiste da oitiva da testemunha Anderson.

Em seguida, pelo Promotor de Justiça foi oferecido aditamento da denúncia, para incluir as substâncias constantes do laudo de fls.281/283.

Pelo defensor foi dito que nada tinha a opor quanto ao aditamento oferecido.

Pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

RECEBO o aditamento ora ofertado, para que conste da denúncia também os entorpecentes descritos no laudo de fls.281/283.

A seguir, pela MM.Juíza foi colhido o interrogatório do réu, pelo sistema virtual.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência da Defesa em relação à testemunha Anderson de Souza Silva.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, ALEXANDRE CONTIERI NOBRE está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei nº11.343/06.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

ADITO A INICIAL PARA INCLUIR NA DENUNCIA AS SUBSTÂNCIAS DESCRITAS NO LAUDO DE EXAME PERICIAL DE FLS. 281-283.

DOS FATOS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de outubro de 2021, por volta de 17h00min, na Travessa José Pereira, n.º53, Bairro Nova América, imediações da unidade policial DEIC – Departamento Estadual de Investigações Criminais, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, ALEXANDRE CONTIERI NOBRE, qualificado e indiciado às fls. 06 e 46/48, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 45 (quarenta e cinco) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, maconha, com peso líquido de 45g (quarenta e cinco decigramas) (item 1) e 01 (um) invólucro plástico contendo Cannabis Sativa L, maconha, com peso líquido de 27,1g (vinte e sete gramas e um decigrama)(item 2), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, o denunciado atuava como motoboy e, paralelamente, comercializava entorpecentes. Para tanto, armazenava os ilícitos em sua residência, um apartamento vizinho ao Departamento Estadual de Investigações Criminais – DEIC –, fazendo rápidas e reiteras paradas no imóvel com sua motocicleta. Ocorre que sua movimentação criminosa passou a ser notada por um policial que frequenta o prédio da unidade policial, sobretudo pela forma, constância e horários das visitas na quitinete.

Na data dos fatos, ALEXANDRE foi abordado no momento que deixava sua moradia.

Questionado sobre sua movimentação corriqueira e suspeita no imóvel, confirmou que possuía drogas e disse que realizava entrega apenas para amigos. Em seguida, autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foram localizadas 46 (quarenta e seis) porções de maconha, R\$207,00(duzentos e sete reais) em espécie, anotações de contabilidade, material plástico comumente utilizado no embalo de entorpecentes e balança de precisão com resquício da mesma droga (vide laudos fls. 22/25 e 108/110 e foto fls. 15).

Além dos entorpecentes acima descritos, foram localizados 01 (um) invólucro constituído por papel alumínio encerrando 25 (vinte e cinco) segmentos de papel ilustrado, do tipo "picote" (selo), e 02 (dois) frascos em vidro contendo fração líquida translúcida e volátil, substâncias semelhantes a LSD (dietilamida do ácido lisérgico) e lança-perfume (cloroeto de etila) (análise pericial específica em andamento).

Na delegacia, ALEXANDRE ficou silente (fls. 06).

Em exame pericial, foi constatada a presença de Tetrahydrocannabinol nas

substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 15/18 e itens 1 e 2 do laudo pericial de constatação fls. 22/25 e 108/110, LAUDOS de fls. 268-270). Diante das circunstâncias, notadamente a visualização policial de constante movimentação na residência, a existência de informações e prisões de traficantes disfarçados de motoboys em aplicativos de entrega, a localização de droga em quantidade incompatível com a destinação pessoal acompanhada de materiais de embalo, balança de precisão com resquício de droga e dinheiro em espécie, é certo que o denunciado guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

ALEXANDRE CONTIERI NOBRE como incurso no artigo 33, caput, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei nº11.343/06

Com relação ao dinheiro apreendido (comprovante fls. 107) e a motocicleta (Honda/CG 160 Titan, DPA-6250, renavam 01211267005) utilizada na prática criminosa.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Marcelo Mendes Lino de Oliveira – Policial Civil – narrou que há algum tempo já suspeitava do réu. Ele residia ao lado do DEIC, vizinho de muro, em um quarto de uma pensão. Ele sempre estava com caixa de entrega e entrava e saía da casa constantemente, cerca de dez vez por dia. Não era normal voltar à própria residência tantas vezes com a caixa de entrega. Não havia motivos para a busca e apreensão, mas entendeu que deveria abordá-lo. No dia, quando viu a moto do réu na rua, com a chave no contato, e o imóvel aberto, encostou a viatura e pediu ajuda a outro policial. Com o policial Leonardo, abordou o réu, que tinha a caixa de entrega nas costas. Questionou-o dizendo que ele tinha atitude suspeita. Perguntou se ele tinha drogas. Ele assumiu que tinha na casa, mas não soube dizer a quantidade. Ele confirmou que fazia a venda de drogas apenas para amigos, mas que não era traficante. Ele franqueou a entrada ao quarto del. No local, ele mostrou onde estava a droga e localizou anotações, lança perfume, balança, contabilidade. Ele disse que tinha resolvido morar perto da delegacia por acreditar que ninguém desconfiaria dele. Pela abordagem, percebeu que o réu não era pessoa “escolada” no crime.

Leonardo Cavalcanti de Oliveira – Policial Civil – no mesmo sentido.

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos. Narraram de forma positiva sobre a vida social e profissional do réu, no sentido de que ele trabalharia fazendo entregas para o Ifood. Apenas Júlio Bonifácio disse que chegou ao local e viu que os policiais estavam dentro da casa do réu, mas não acompanhou a abordagem ou revista no local.

Interrogado, o réu disse trabalhar como motoboy. Justificou-se pelo fato de entrar em casa várias vezes porque trabalha com entregas para aplicativo e por isso sempre ia ou ficava em casa para pegar uma blusa ou usar o banheiro. Quanto às drogas, guardava para um amigo, cuja identidade prefere não falar. No dia da abordagem, foi buscar uma blusa em casa e foi abordado. Não fazia entrega de drogas com a motocicleta. As anotações eram referentes a uma festa e não a drogas. Não fornecia drogas para amigos.

Não há dúvidas sobre os fatos.

Drogas apreendidas na casa do réu, fato inclusive por ele confirmado. O destino ao tráfico resulta da quantidade, quantidade e diversidade.

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: “A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o

agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10)

DA PENA

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 34/37): ALEXANDRE CONTIERI NOBRE é primário e menor de 21 anos.

É o caso de reconhecer o aumento da pena com base no art. 40, III, da Lei de Drogas.

Possível, também, a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, reconheceu que o chamado "tráfico privilegiado de drogas" não tem natureza hedionda.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acompanhou o entendimento da Corte Superior e cancelo a Súmula 512.

Com isso, entendo possível, no presente caso, acompanhando o posicionamento das Cortes Superiores, a fixação de regime aberto e a substituição por restritiva de direitos.

Não é o caso de perdimento da motocicleta porque a droga não foi apreendida em situação de que era transportada no veículo nem há prova inequívoca de tráfico com o uso deste.

DO PEDIDO FINAL

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra ao nobre defensor do acusado, manifestando-se sua Excelência, conforme gravação no Teams.

Em seguida pela MM.Juíza foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ALEXANDRE CONTIERI NOBRE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de outubro de 2021, por volta de 17h00, na Travessa José Pereira, n.º 53, Bairro Nova América, imediações da unidade policial DEIC - Departamento Estadual de Investigações Criminais, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, guardava e tinha em depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 45 (quarenta e cinco) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L., maconha, com peso líquido de 45g (quarenta e cinco decigramas) (item 1) e 01 (um) invólucro plástico contendo Cannabis Sativa L.,

maconha, com peso líquido de 27,1g (vinte e sete gramas e um decigrama) (item 2) , sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, o réu atuava como motoboy e, paralelamente, comercializava entorpecentes. Para tanto, armazenava os ilícitos em sua residência, um apartamento vizinho ao Departamento Estadual de Investigações Criminais - DEIC -, fazendo rápidas e reiteradas paradas no imóvel com sua motocicleta.

Ocorre que sua movimentação criminosa passou a ser notada por um policial que frequenta o prédio da unidade policial, sobretudo pela forma, constância e horários das visitas na quitinete.

Na data dos fatos, ALEXANDRE foi abordado no momento que deixava sua moradia. Questionado sobre sua movimentação corriqueira e suspeita no imóvel, confirmou que possuía drogas e disse que realizava entrega apenas para amigos.

Em seguida, autorizou a entrada dos policiais no imóvel, onde foram localizadas 46 (quarenta e seis) porções de maconha, R\$207,00 (duzentos e sete reais) em espécie, anotações de contabilidade, material plástico comumente utilizado no embalo de entorpecentes e balança de precisão com resquíio da mesma droga (vide laudos fls. 22/25 e 108/110 e foto fls. 15).

Além dos entorpecentes acima descritos, foram localizados 01 (um) invólucro constituído por papel alumínio encerrando 25 (vinte e cinco) segmentos de papel ilustrado, do tipo "picote" (selo), e 02 (dois) frascos em vidro contendo fração líquida translúcida e volátil, substâncias semelhantes a LSD (dietilamida do ácido lisérgico) e lança-perfume (cloreto de etila).

Na delegacia, ALEXANDRE ficou silente (fls. 06).

Em exame pericial, foi constatada a presença de Tetrahydrocannabinol nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 15/18 e itens 1 e 2 do laudo pericial de constatação fls. 22/25 e 108/110).

Diante das circunstâncias, notadamente a visualização policial de constante movimentação na residência, a existência de informações e prisões de traficantes disfarçados de motoboys em aplicativos de entrega, a localização de droga em quantidade incompatível com a destinação pessoal acompanhada de materiais de embalo, balança de precisão com resquíio de droga e dinheiro em espécie, é certo que o réu guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 117/118), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 123/124).

O réu foi notificado (fls. 177) e apresentou defesa preliminar, na qual requereu rejeição da denúncia, diante da ilicitude da prova, obtida sem a existência de mandado judicial de busca residencial. No mérito, se reservou para os debates (fls. 181/192).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência (fls. 249/253). O réu foi citado (fls. 299).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas comuns e 02 testemunhas de defesa. A denúncia foi aditada, para descrever as demais substâncias entorpecentes, do laudo pericial de fls. 281/283. A Defesa se manifestou e o aditamento foi recebido. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais e debates orais, as partes se manifestaram. É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

1) Alegou a Defesa que a prova é nula, na medida em que o policial civil não poderia abordar o réu, sem que houvesse suspeita na sua conduta.

Ocorre, contudo, que o policial civil suspeitou da conduta do réu, que saía várias vezes da sua casa, em vários horários, com a caixa de entrega nas costas, saindo rapidamente. Por isso, no dia dos fatos, o réu se encontrava em via pública, quando foi abordado.

E mais, tratando-se de abordagem na via pública, há entendimento jurisprudencial no sentido da desnecessidade de justa causa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS

OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por policiais militares quando, ao avistar os agentes, correu para dentro de sua residência. 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 3. "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial" (REsp 1.574.681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 30/05/2017). 4. No caso, o ingresso dos policiais na residência do Paciente foi amparado tão somente no fato deste ter adentrado rapidamente em sua residência ao avistar os agentes, o que por si só não caracteriza elemento objetivo apto a legitimar a medida. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.352/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022) - grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. FUGA DO AGENTE E DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 2. "A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial (HC n. 415.332/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/8/2018). 3. Hipótese em que a simples fuga do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 132.343/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021) - grifei

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. (...) 12. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo recorrido, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o consentimento do morador - que deve ser mínima e seguramente comprovado - e sem determinação judicial. (...) 15. Recurso provido, ex officio, para reconhecer, nos Autos n. 0024.19.100.161-9, a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o recorrente, com fulcro no art. 386, II, do CPP, determinando, assim, a sua imediata soltura. (RHC 118.817/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

2) Aduziu a Defesa, também, a ilicitude da prova, diante do fato de que os policiais ingressaram na residência do réu apenas com base em fundada suspeita, sem que houvesse qualquer investigação anterior e sem respaldo em mandado judicial. A inviolabilidade da casa é a regra constitucional, mas a própria Lei Maior indica exceções.

Dispõe o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nesse sentido, em caso de flagrante delito, é possível que agentes policiais ingressem na residência, mesmo ausente mandado judicial ou sem autorização do morador.

Sobre a questão, em recurso extraordinário representativo de controvérsia, assim se manifestaram os Ministros da Corte Suprema:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016 - grifei).

Assim, mesmo sem mandado judicial, tratando-se o crime de tráfico de drogas permanente, os policiais civis tinham a possibilidade de ingresso na residência, desde que houvesse justa causa.

E a justa causa encontra abrigo nos autos.

Como se verifica da prova oral, os policiais tinham suspensão da conduta ilícita do réu, em razão de suas movimentações e, por isso, no dia dos fatos, como viram a motocicleta do réu estacionada na frente do imóvel e o portão totalmente aberto, aguardaram para abordá-lo. Aliás, a situação vem corroborada na fotografia de fls. 14.

Assim, a suspeita não foi motivo para o ingresso na residência, mas sim para a abordagem do réu na calçada, em frente à residência, quando ele saía do local. Assim é que, quando o réu deixou a casa, foi abordado, na calçada, e indagado sobre a existência de drogas, o réu confessou, dizendo que tinha algum entorpecente dentro da sua casa, entregando a chave e autorizando o ingresso. Note-se que o próprio réu confirmou que disse que confirmou a existência de drogas na sua casa. Assim, o réu foi abordado fora da residência e, indagado sobre a existência de

drogas acabou confessando aos policiais, havendo certeza da existência de drogas, quando os agentes ingressaram na casa.

Nesse sentido:

Em que pese a inviolabilidade domiciliar, o estado flagrancial, como predisposto pela Constituição Federal, é medida excepcional. Perfilhando o Auto de Prisão em Flagrante, percebo que o ingresso domiciliar deu-se em função de o réu ter asseverado, quando abordado por atitude suspeita nas ruas, possuir mais entorpecentes em seu domicílio, ensejando o deslocamento das autoridades policiais à casa. Sob tais circunstâncias, o flagrante delito torna-se perfeitamente válido, porquanto subsistia a prática da infração, na medida em que os entorpecentes foram encontrados dentro da localidade em que o acusado apontou como seu domicílio, ali alocados em uma caixa de perfumes, a conduta incorrendo no verbo “guardar”, nas conformidades do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Por consequência, não há ferimento ao princípio da inviolabilidade domiciliar, superado pelo estado flagrancial. Os Policiais Militares estavam munidos de indícios suficientes que delatassem a prática do crime intra muros, o próprio réu confessando a manutenção da droga. (STJ - HC: 732676 GO 2022/0092070-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 01/07/2022)."

Ademais, os policiais tinham autorização do réu para o ingresso na residência, o que torna lícita a ação policial.

Assim já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 162709 - SP (2022/0087828-9) DECISÃO Conforme relatado, busca-se com o presente recurso a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Inicialmente, destaco que o pedido de declaração de nulidade da busca domiciliar não comporta conhecimento. Isso porque foram formulados pedidos idênticos em benefício do mesmo recorrente no HC n. 692.133/SP de minha relatoria, o qual foi julgado na sessão do dia 8/3/2022, pela e. Quinta Turma desta Corte Superior, que desproveu o agravo regimental interposto no writ em questão. O acórdão restou assim ementado: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGRAVADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE. REINCENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. No caso em análise, consta dos autos que o agravante autorizou a entrada dos policiais militares no imóvel que, mediante o auxílio de um cão farejador, encontraram as porções de droga na área dos fundos da casa, no telhado, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial. Assim, não há falar em nulidade do flagrante decorrente da violação de domicílio. (STJ - RHC: 162709 SP 2022/0087828-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/07/2022 - grifei).

II - Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 10/12, nas fotografias de fls. 13/15, no laudo de constatação de fls. 22/25 e nos exames químico-toxicológicos de fls. 281/283 e 285/288, segundo o qual foram detectadas as presenças de Tetrahydrocannabinol (THC), 25B-NBOH e 25E-NBOH, constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e Cloreto de

Metileno/Diclorometano, nas substâncias apreendidas.

O exame químico-toxicológico de fls. 108/110 confirmou a existência de Tetrahydrocannabinol (THC) na balança apreendida.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos. Vejamos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05/06).

Em Juízo, o réu disse que entrava e saía de casa, porque morava numa área central e, como trabalhava como aplicativo, ia para casa para pegar blusa, usar banheiro. Só fazia entrega de comida pelo aplicativo. As drogas que foram encontrada na sua casa não eram dele, mas sim de um amigo, cujo nome não pode revelar. No dia dos fatos, foi para casa para pegar uma blusa e parou a moto na frente de casa, pegou a blusa e logo saiu, sendo abordado. Ele disse eu tinha denúncia de que estava fazendo Delivery de drogas. Ele tirou a chave da sua moto e logo pediu a chave da sua casa. Mostrou onde era a casa e eles já entraram. Disse aos policiais que tinha droga na sua casa. Os policiais ingressaram na sua casa e acompanhou a revista. Os policiais encontraram sacola com as porções menores de maconha, uma porção maior de maconha, uma cartela de LSD, balança, 02 garrafas de lança-perfume. Nenhuma droga era sua. As anotações não eram de tráfico, mas sim de uma festa que tinha organizado, para saber o rateio do dinheiro que cada amigo devia. Não fornecia drogas para os amigos. Não faz uso de drogas.

A negativa foi afastada pelas demais provas existentes nos autos. Vejamos.

O policial civil Marcelo Teixeira Mendes Lino de Oliveira asseverou que já vinha suspeitando do réu há algum tempo. Ele residia ao lado do Deic, em um imóvel com vários quatinhos, como quitinete. Chamava a atenção de que chegava cedo para trabalhar, ele estava saindo com a caixa de entrega e fazia o mesmo durante todo o dia. Ficava intrigado sobre o que ele pegava na casa e levava, durante o dia todo. Não é normal o entregador ir à residência o dia todo, inclusive à noite. Tinha a intenção de abordá-lo na rua e combinou que iria fazer isso. No dia dos fatos, saía sozinho do estacionamento e, quando saiu, viu a motocicleta do réu na via pública com a chave no contato e com o portão aberto. Ligou para seu parceiro, avisando que o menino estava para sair. Leonardo já saiu da Delegacia a pé. O réu saiu da casa com a caixa de entrega nas costas e foi abordado por ele. Leonardo estava saindo na calçada da Delegacia, quando fez a abordagem, de forma que visualizou toda a abordagem e dela participou. Pediu documentos pessoais e da motocicleta e lhe disse que sua atitude era suspeita, perguntando se havia drogas, se fazia entrega de drogas. Ele respondeu que, com ele, não havia drogas, mas na casa sim. Ele falou que fazia a venda de drogas para amigo e, por isso, não era traficante. Perguntou onde estavam a droga e ele disse que era na sua casa, onde morava sozinho. Ele mesmo entregou a chave do quarto, os acompanhou e, na casa, indicou onde estava a droga. Eram drogas, 45 porções de maconha embaladas separadamente, uma porção de maconha maior, micropontos de LSD, 02 garrafas de lança-perfume, balança de precisão, contabilidade da droga, material de emalo. O réu falou que os pais não aceitavam coisas relacionadas à sexualidade e, por isso, se mudou ao lado da Delegacia, achando que não chamaria a atenção. Percebeu o réu com essa atitude suspeita há 20 dias, pelo menos. O próprio réu colaborou e indicou onde estava a droga. O réu, desde o início, foi sincero. Ele forneceu a chave da casa, franqueou a entrada e foi bem tranquilo. Não conhecia o réu. Não fizeram campanas, foi coincidência de que a moto estava no contato e o portão aberto. Chegava ou saía da Delegacia e via o réu chegando ou saindo. Nunca fez campanas.

No mesmo sentido, o também policial civil Leonardo Cavalcanti de Oliveira asseverou que dias anteriores, o policial Marcelo estava desconfiado de um motoqueiro, que residia ao lado da base. Começaram a verificar a conduta suspeita dele, porque ele chegava com a maleta térmica nas costas, entrava na residência e logo saía. No dia dos fatos, estavam em um flagrante e o policial Marcelo saiu para abastecer a viatura e ligou no seu celular e falou que o rapaz estava saindo, com a moto na via pública e que o iria abordar. Saiu da Delegacia e, no portão, já viu a moto parada na frente da casa. O rapaz estava dentro da casa, mas já saiu e já viu Marcelo o abordando. Marcelo pediu documento dele e da moto e comentou a respeito do comportamento suspeito. Marcelo perguntou se tinha droga e o réu falou que não, que

só tinha droga na sua casa. Ele disse que a droga era para seu consumo próprio, forneceu a chave, acompanhou a viatura. Numa cômoda, havia 45 porções fracionadas de maconha. Essa maconha, o réu falou que era para seu consumo e que, eventualmente, os vendia para amigos. Em busca no imóvel, localizaram 02 garrafas de lança-perfume, uma porção maior de maconha, micropontos de LSD, balança, anotação com nome de indivíduos e valor que estava devendo, material de embalo. O réu foi abordado na via pública. O imóvel tem um corredor, com vários cômodos individuais. Não conhecia o réu.

Jean Lucas Gonçalves Peniche asseverou que trabalhava com o réu, no barracão da Drogal, na parte do estoque, cada um num estoque. Trabalharam juntos por 02 anos, das 12h15 até às 22h00. Na época dos fatos, já não trabalhavam mais nesse local. Pelo que saiba, quando pararam de trabalhar juntos, o réu foi trabalhar com entrega, com aplicativo Ifood. Não sabia de envolvimento do réu com drogas. Júlio César Bonifácio narrou que mora no mesmo imóvel que o réu. Como tinha pouco convívio com o réu e o via poucas vezes, o via como motoboy, com a caixa nas costas, quando chegava do trabalho ou quando saía para o trabalho. Não sabia que o réu tinha envolvimento com drogas. Viu que tinha alguns policiais na casa do réu, com cão policial. Viu 03 policiais. Não viu o réu sendo abordado. O policial perguntou se sabia que o réu mexia com drogas e disse que não.

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Na Delegacia, o réu manteve-se em silêncio. Judicialmente, o réu aduziu que foi abordado na via pública, confirmou que havia droga na sua casa. Aduziu que a droga era de terceira pessoa, para quem guardava, negando que trabalhasse com o delivery de drogas.

O policial civil Marcelo narrou que já vinha suspeitando da conduta do réu, que reside ao lado do DEIC, metros ao lado do portão da garagem da Delegacia, um imóvel que se trata de uma pensão, com várias quitinetes. O réu era visto acessando o imóvel várias vezes ao dia, sempre com uma caixa de entrega nas costas, em horários incompatíveis com entrega de refeições, entrando e saindo em minutos ou segundos. Na data dos fatos, quando Marcelo saía pela garagem da Delegacia para abastecer a viatura, viu que a motocicleta do réu estava estacionada na frente do endereço e o portão totalmente aberto, indicando que o réu sairia da casa, em pouco tempo. Marcelo ligou para o policial Leonardo, que estava dentro da Delegacia, pedindo que fosse ao local. Enquanto Leonardo saía pelo portão da garagem e caminhava em direção a Marcelo, o réu saiu da casa e foi abordado por este último policial. Leonardo se aproximou na sequência. O réu foi cientificado sobre a observação que Marcelo tinha feito sobre as suas movimentações e questionado se teria drogas em sua residência, tendo respondido positivamente, dizendo ser usuário de drogas e que só as vendia esporadicamente, aos amigos. O próprio réu autorizou o ingresso dos policiais na sua casa, fornecendo as chaves, e indicou onde estavam as drogas. Numa cômoda, ao lado da cama, os policiais apreenderam 45 porções de maconha, 1 porção maior da mesma droga, micropontos de LSD, duas garrafas de lança-perfume, além de material para embalo e balança. Havia, ainda, um caderno com anotações do tráfico. O réu confirmou aos policiais que trabalhava como motorista de aplicativo de entrega, porém, também vendia drogas aos amigos.

As testemunhas de defesa nada puderam acrescentar sobre os fatos, que não presenciaram.

O réu confirmou que estava na guarda da droga apreendida, que foi localizada em sua residência, de forma que não há contradição sobre a localização da droga. Ainda que assim não fosse, a palavra dos policiais, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, em especial, como no caso dos autos, quando amparada pelo restante da prova.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta

Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Comprovado o envolvimento do réu com a droga apreendida, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprova a traficância. O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu aduziu que a droga era de terceira pessoa, para quem a guardava. A prova dos autos indica que o entorpecente tinha mesmo como destino o consumo de terceiras pessoas. Vejamos.

Inicialmente, o policial Marcelo estava suspeitando da movimentação do réu, que reside ao lado da garagem da Delegacia, ingressava em horários variados, rapidamente, acessando o local com chave própria, sempre com caixa de entrega nas costas. Essa suspeita já tinha sido passada ao colega Leonardo.

No dia dos fatos, Marcelo viu que a motocicleta do réu estava estacionada na frente da casa e o portão aberto e, sabendo que ele sairia rapidamente, aguardou-o, para abordagem.

Ao ser questionado se teria entorpecentes no local, Alexandre confessou, dizendo-se usuário e que vendia droga somente para amigos.

Ele forneceu as chaves do imóvel aos policiais e autorizou a entrada no imóvel.

Além disso, indicou uma cômoda localizada ao lado de sua cama, onde os entorpecentes foram encontrados.

A quantidade e diversidade de droga apreendida (45 porções de maconha, uma porção maior da mesma droga, micropontos de LSD, duas garrafas de lança perfume) não são comumente encontradas com usuários.

Além disso, foram apreendidas anotações de contabilidade (laudo de fls. 136/138), que descrevem atividade negocial, com nome de pessoas e quantidades, indicando a venda de entorpecentes; além de balança com resquício de Tetrahidrocannabinol (THC) (laudo pericial de fls. 108/110), dinheiro em espécie e material para embalo das drogas.

A forma de embalagem da droga também indica a atividade mercantil (vide fotografia de fls. 13).

Assim, a movimentação presenciada pelo policial, a quantidade da droga, a forma de embalagem do entorpecente, a localização de droga em quantidade incompatível com a destinação pessoal acompanhada de materiais de embalagem, balança de precisão com resquício de droga e dinheiro em espécie; tudo revela que a droga na posse do réu tinha como destino o consumo de terceiros pessoas.

A condenação, assim, é de rigor.

3) Da causa de aumento da pena

Como se verificou pelas considerações acima, o réu guardava e tinha em depósito entorpecentes na sua casa, que fica a 10 metros de distância do portão da garagem do Deic, segundo a testemunha Marcelo ou a 94 metros do portão de entrada da mesma Delegacia, consoante informação juntada aos autos pelo Ministério Público a fls. 118.

Dispõe o artigo 40 da Lei nº 11.343/06: "As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos". Nesse sentido, o fato de o crime ser cometido nas proximidades de unidade policial traz ainda mais reprovação à conduta e a causa de aumento deve ser reconhecida. Nem se diga que o réu não se utilizava da unidade policial para a prática do delito e, por isso, não pode ser aplicada a causa de aumento, na medida em que basta a situação fática para que se aplique o aumento.

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS PARA A CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DELITIVA. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO ENVOLVE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. MAJORANTE. RECONHECIMENTO. IMEDIAÇÕES DE UNIDADE DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. PRECEDENTES. REDUTORA. NÃO APLICABILIDADE. ANIMUS ASSOCIATIVO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. O Tribunal de Justiça reconheceu a majorante mesmo em período de férias escolares, o que não contraria a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades. (AgRg no AREsp 1860725/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 2/3/2022). (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp n. 1.926.887/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022 - grifei).

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Redução da pena-base - Inviabilidade - Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 - Afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Basta estar nas mediações dos locais estabelecidos pela Lei de Drogas para a configuração da majorante - Condição objetiva - Aplicação do redutor - impossibilidade - Regime fechado único possível - - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1500021-29.2022.8.26.0066; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes criminais, de forma que sua pena-base deve ser

calculada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

A menoridade e a confissão não são capazes de trazer a pena aquém do mínimo legal.

A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 fará com que a pena seja aumentada em um sexto: reclusão de 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 pode ser reconhecida no caso concreto. Vejamos. O réu é primário, a quantidade de droga apreendida não era excessiva e não há notícias de que ele se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa. Assim, tem direito à redução:

reclusão de 01 ano, 11 meses e 10 dias e 194 dias-multa.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

Diante da jurisprudência que vem se fixando nos Tribunais Superiores, o regime inicial de pena cominada ao delito de tráfico de entorpecente privilegiado deve ser o aberto.

Pena final: reclusão 01 ano, 11 meses e 10 dias, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR ALEXANDRE CONTIERI NOBRE, qualificada nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 01 ano, 11 meses e 10 dias, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, diária mínima.

Tendo em vista as novas orientações jurisprudenciais, como o réu é primário e o crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido com